



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/38/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן**

התובעים:

1. אגודה שיתופית קיבוץ תמוז
 2. שני אורסתיו
 3. יאיר אלברטון
 4. שלומית אלברטון נחליאל
 5. אמיר ברוך
 6. ניצן ברוך
 7. ערן וישנקו
 8. דקלה עובד
 9. דגנית לוי
 10. אבנר ישראלי
 11. תמר גולדמן
 12. אסנת אלנתן
 13. חנן כהן
 14. אביתר כפכפי
 15. עינת רביב
 16. רן רביב
 17. תמרי גלעד יקונט
 18. חגי גלעד יקונט
 19. גילי גופר
- ע"י ב"כ עוה"ד מרים היילברון
מרחוב בן יהודה 1 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים:

1. יניב לוי
 2. דליה לוי
- ע"י ב"כ עוה"ד אבי וינברגר
מרחוב הגדוד העברי 10 אשקלון

פסק דין

המחלוקת בהליך זה עניינה בשימושים ועבודות בנייה שביצעו הנתבעים בדירתם, ברכוש המשותף ובשטח אדמה סמוך לדירתם - האם כדין?

טענות הצדדים והתנהלות ההליך

טענות התובעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. התובעת 1, קיבוץ עירוני, זכאית להירשם כחוכרת של שטח קרקע ברחוב הנשיא ויהודה המכבי בבית שמש הידוע כחלקה 204 בגוש 5211. התובעת 1 בנתה על המקרקעין 4 מבנים בהם 24 דירות והינה זכאית לבנות עוד 9 דירות נוספות בשטח החלקה. מלוא זכויות הבניה במקרקעין שייכות לה. הבתים ראויים להירשם כבית משותף ובהתאם חלות הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין.
2. בנוגע ל- 16 מתוך הדירות שנבנו נחתמו הסכמי חכירה עם חברי קיבוץ אשר נרשמו אצל רשות מקרקעי ישראל כבעלי הזכויות (התובעים 19-2), אם כי התובעת 1 הינה בעלת הזכויות המהותית בדירות על פי החלטת אסיפת הקיבוץ, 2 דירות נרשמו על שם התובעת 1 ו- 6 דירות נמכרו בסופו של יום לצדדים שלישיים. הנתבעים רכשו את אחת הדירות האמורות.
3. התובעת טוענת כי הנתבעים ביצעו פעולות אשר הביאו להשתלטות על רכוש התובעת או הרכוש המשותף ובכלל האמור השתלטו על שטח מדרכה ושטח נוסף השייך לתובעת 1 אשר שימש כגינה ומגרש חניה ונועד לבניית יחידות דיור נוספות תוך שהם עוקרים עץ פרי, מגדרים את השטח, מרצפים אותו בבטון, מתקינים פינת ישיבה, חניה פרטית ודק עץ; הנתבעים סגרו את המרפסת הפתוחה בדירתם ומשתמשים בה למגורים שלא כדין; הנתבעים החלו בביצוע עבודות בניה בדירתם כולל חפירה מתחת לדירה ולמרפסת, ללא היתר כדין ותוך פגיעה בזכויות התובעת 1. בהקשר זה נטען כי שטחי המילוי אינם צמודים לדירת הנתבעים וגם אין להם כל זכויות בניה בבית.
4. למען הסדר הטוב אזכיר כי תחילה הוגשה התובענה על ידי התובעת 1 בלבד. התובעים 2-19 צורפו להליך, לבקשתם, בהתאם להחלטה מיום 06.02.14.
5. ביחד עם כתב התביעה הוגשה גם בקשה למתן צו מניעה זמני בתיק ב"ב 01/39/2014. ביום 18.02.14 ניתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעים לבצע כל פעולות בנייה או הריסה בשטח הסמוך לדירתם וברכוש המשותף, לרבות, חפירה מתחת לדירה, הפיכת חלל למגורים או חיבור שטח זה לתשתיות.
6. להוכחת טענותיהם הוגשו מטעם התובעים תצהירים חתומים על ידי התובעים 2 ו- 3.

טענות הנתבעים

7. התביעה הוגשה בשיהוי וללא כל בסיס עובדתי ומשפטי – העבודות בוצעו על פי הסכמת התובעת וכל בעלי הדירות בבית בו מצויה דירת הנתבעים. לתובעת 1 גם אין כל זכויות במקרקעין או ברכוש המשותף של הבית הנדון שדירותיו נמכרו לרוכשים שונים – כל מעמדה של התובעת 1 הינו כחברה משכנת בלבד. כל טענות התובעת באו אך בשל תלונות הנתבעים בשל בניה בלתי חוקית שמבצעת התובעת 1. הבניה בדירת הנתבעים – סגירת המרפסת, בוצעה על פי היתר בניה כדין והתובעת איננה יכולה לחזור בה מהסכמה שנתנה לעבודה זו. לא בוצעה כל חפירה מתחת לדירת הנתבעים. השטח הצמוד לדירת הנתבעים נוקה על ידם וגודר על פי הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, באישור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/38/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת 1 ובידיעתה. מדובר בשטח השייך לבית בו דירת הנתבעים ולא בשטח חניה כנטען.

8. מטעם הנתבעים הוגשו תצהירים חתומים על ידי הנתבע 1 ומר דניאל צרפתי – מהנדס העיר בית שמש.

9. יוער כי במקור תובענה זו נשמעה על ידי המפקח הבכיר שלומי הייזלר. עם מינויו של האחרון לתפקיד הממונה על המרשם הועבר התיק בפניי למתן פסק דין בתובענה.

10. לאחר שהצדדים מיצו תקופה ארוכה לניהול מו"מ ולא הגיעו לכדי הסכמות הוגשו סיכומים מטעמם בהליך.

11. לשם בחינה בלתי אמצעית של מצב הבית בסוגיות הנדונות בהליך זה נערך על ידי ביום 09.10.16 ביקור במקום לאחריו הודיעו הצדדים במשותף כי הם מבקשים את הכרעתי בהליך.

דיון והכרעה

עבודות חפירה

12. לא עלה בידי התובעים להוכיח כי בוצעו או מבוצעות עבודות חפירה כלשהן בדירת הנתבעים - הראיה היחידה בידם בהקשר זה הינה כי, לכאורה, נצפו פועלים וחומרי עבודה (סעיף 13 לתצהיר אלברטון וסעיף 11 לתצהיר אור-סתיו).

13. מאידך, מעדות הנתבע עולה כי הנתבעים לא ביצעו עבודות כאמור (סעיף 23 לתצהירו). כך גם עלו הדברים כבר במועד הדיון בבקשה לסעד זמני (עמוד 2 שורות 3-5). מעדותו של מר צרפתי עולה כי בביקור שערך בדירת הנתבעים, לבקשת היועץ המשפטי של העירייה, הוא לא מצא כל עבודות חפירה (סעיף 7 לתצהירו וכן נספח 8 לתצהיר לוי), ועדותו זו לא הופרכה (ר' למשל עמוד 3 שורות 16-22 וגם בהמשך עדותו באותו עמוד). גם בביקור במקום לא נצפתה כל חפירה בבית או כל עבודות מתבצעות (עמוד 2 שורות 13-16).

14. לאור האמור הרי שאין מקום ליתן כל סעד נדרש בנוגע לעבודות שאינן מבוצעות. בהתאם, גם אין מקום ליתן צו האוסר שימוש או חיבור לתשתיות של "חפירה" שלא הוכח כי בוצעה או עתידה להתבצע.

15. אולם, כדי למנוע מחלוקות עתידיות ולאור ההצהרה המפורשת של הנתבעים בדיון מיום 18.02.14 כי "אני מצהיר כי אינני מתכוון לעשות כל עבודה נוספת מחוץ לבית ובכלל זה מתחת למרפסת, מתחת לבית או בכל שטח אחר מסביב לבית" (עמוד 2 שורות 3-4), נכון יהיה להבהיר כי הנתבעים אינם רשאים לבצע כל עבודות כאמור וזאת כל עוד לא התקיימו הוראות תיקון 18 לחוק המקרקעין (כמפורט בסימן 11 לפרק 1 לחוק החל על הבית דנן בהתאם להוראות סעיף 77ב) במלואן, לרבות, קבלת היתר בניה לביצוע העבודות, הסכמה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קניינית נדרשת של רוב בעלי דירות בבית והסכמת התובעת על פי הסכם הפיתוח בכל הקשור לזכויות בניה כפי שידון עוד להלן.

16. במיוחד נכונים הדברים לאור העובדה כי כעת הזו גם אין כלל אפשרות תכנונית לבצע עבודות חפירה כאמור - כך עולה מהעובדה כי בקשה לקבלת היתר בניה בהקשר זה מצד הנתבעים נדחתה (ר' עדות צרפתי בעמוד 3 שורה 44) ומחמת היעדר אחוזי בניה פנויים נוספים לדירה (ר' הזכויות המקסימליות המאושרות לדירה בנספח 6 לתצהיר לוי).

הרחבת הדירה

17. בביקור במקום התברר כי הנתבעים ביצעו עבודות בדירתם ובכלל האמור בכל שטח המרפסת הפתוחה כפי שהיתה במקור (ועודנה כזו בדירות אחרות בבית כפי שנראו בביקור במקום) - נבנה חדר נוסף וחלק אחר נסגר, אוחד לדירה ומשמש כפינת אוכל (עמוד 2 שורות 14-16). כך גם עולים הדברים מחקירת מר לוי (עמוד 12 שורות 10-17), יוער, בניגוד מפורש לנטען בתצהירו (סעיף 22).

18. הוכח בפניי כי מצב דירת הנתבעים בפועל כאמור אינו תואם לאישור התכנוני שניתן בידם - כך עולה מעדות מר צרפתי כי לנתבעים היתר לסגירת חדר בגודל של 10 מ"ר ומרפסת פתוחה בגודל כ- 12 מ"ר (עמוד 2 שורות 30-31). הדברים גם עולים לכאורה ממסמכי הרישוי שצורפו (נספחים 6 ו-7 לתצהיר לוי). הגדרתו של מר צרפתי מהי "מרפסת פתוחה" איננה תואמת לחלוטין את המצב הפועל בדירת הנתבעים כפי שעלה בביקור במקום - מדובר על פינת אוכל המשמשת כחלק בלתי נפרד מהדירה לכל דבר ועניין (עמוד 2 שורות 33-36). גם מר צרפתי מאשר, במפורש, כי הבניה בדירת הנתבעים איננה תקינה ולא תואמת את המצב התכנוני המאושר (ר' עמוד 4 שורות 40-42 ועמוד 5 שורות 1-3).

19. די בדברים האמורים, בשילוב עם הצהרתו המפורשת של מר לוי בדיון מיום 09.11.14 כי - "אני מוכן כבר עכשיו להתחייב על השבת המצב לקדמותו באופן שיהיה בדיוק לפי היתר הבנייה המתוקן. מעבר לכך אני לא מוכן להצהיר על שום דבר" (עמוד 15 שורות 29-30), כדי להביא לקבלת התביעה בכל הקשור לבניה אשר חורגת מהיתר הבניה.

20. במיוחד האמורים הדברים כאשר הוכח כי כלל אין עוד זכויות בניה עיקריות אשר ניתנות למימוש (ר' עדות צרפתי בעמוד 2 שורות 15-17) וכי הבניה בוצעה והשימוש בה נעשה עוד לפני קבלת היתר בניה (עמוד 12 שורות 22-23).

21. זאת ועוד. אף אם נקבל את גרסת הנתבעים לפיה נדרשת הסכמה של בעלי הדירות במבנה בלבד לשם ביצוע פעולות בניה בדירתם הרי שלא הוכחה על ידם קיומה של הסכמה של בעלי הדירות האמורים לכל הבנייה שבוצעה בפועל.

22. בהתאם להלכות שנפסקו עם השנים הרי שההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)). הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה, אך במקרה שכזה עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות - אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרד, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)). עוד קובעת ההלכה כי הסכמה כאמור אין הכרח שתתקבל במסגרת אסיפה כללית וניתן גם לקבלה גם במסגרת הסכמות פרטניות של בעלי הדירות. כך נפסק בע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזוד (לא פורסם)).

23. בנסיבות דנן דבר קיומה של הסכמה להרחבה החורגת מעבר להיתר הבניה, לא הוכח על ידי הנתבעים.

24. ראשית, לא הובאה כל ראיה בדבר קיומה של הסכמה קניינית מפורשת של בעלי הדירות בבית – לא הוצג כל מסמך, חתימה ואלו אף לא זומנו לעדות. צירוף של מכתבים מצד אותם בעלי דירות נוספים בנוגע לשימוש בחצר בלבד מחזק את המסקנה כי הסכמה קניינית לבנייה כלל לא הייתה קיימת – אין כל אזכור במסמכים שהוגשו (ללא כל קשר לערכם הראייתי בהעדר עדות של עורכייהם) להסכמה בנוגע להרחבת הדירה (ר' נספחים 3 ו- 4 לתצהיר לוי). בפרט אמורים הדברים לאור סיכום האסיפה מיום 10.04.08 במסגרתו הבהירו בעלי הדירות, והנתבעים בניהם, כי לבד מהשינויים המפורטים שם (ואשר אינם נדונים בהליך זה) לא יבוצע דבר נוסף (ר' נספח ה לתצהיר אלברטון).

25. שנית, לא הוכחה קיומה של הסכמה פוזיטיבית מפורשת במסגרת ההליך התכנוני – לא הוגש דבר ממסמכי הרישוי בהקשר זה. ויודגש, מן העדויות בהליך זה עולה כי לכאורה קיימת הסכמת בעלי הדירות, ודאי במסגרת ההליך התכנוני (ר' עדות צרפתי בעמוד 3 שורות 7-9). אין כל הסבר מדוע הסכמות אלו לא צורפו ובהתאם להלכה ניתן להסיק מסקנה ראייתית הפועלת כנגד הנתבעים ולפיה לא ניתן להסיק מהסכמות אלו גם קיומה של הסכמה קניינית נדרשת בכל הקשור לבנייה אשר חורגת מהיתר הבניה (ר' ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651)).

26. לאור האמור לעיל אני מוצא לנכון לקבל את התביעה בחלקה ולהורות על הריסת הבניה אשר חורגת מהיתר הבניה ובכלל האמור על הנתבעים לפתוח את המרפסת הפתוחה, לרבות, הקירוי והחלונות החיצוניים.

27. למען שלמות התמונה אבהיר כי בנוגע להרחבת הדירה על פי היתר הבניה הרי שלא עלה בידי התובעים להוכיח כי בניה זו חורגת מאשר זכויותיהם היחסיות של הנתבעים בבית וממילא גם לא הוכח כי יש בבניה זו כדי לגרום נזק כלשהו למי מהתובעים. ובמה דברים אמורים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. ראשית, הוכח בעדותו של מר צרפתי כי היתר הבניה ניתן על פי השטח המותר לבניה בכל דירה בהתאם לתוכנית החלה במקום (עמוד 2 שורות 25-13 וסעיף 5 לתצהיר). כך עולה הדבר גם מהחלטת רשות הרישוי (נספח 6 לתצהיר לוי) - בהתאם, מדובר בזכויות בניה אשר ניתנות לשימוש בדירה בלבד ועל גבי שטח שאין מחלוקת כי הוא צמוד לה. למעשה, גם עדי התביעה מאשרים את האמור בעדותם (ר' עדות הגב' אורסתי בעמוד 8 שורות 38-42 ועדות מר אלברטון בעמוד 10 שורות 27-26).

29. שנית, המתחם בכללותו, והבית בפרט, טרם נרשמו כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ובהתאם חלות על הבית הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין אשר מגדירות את חלקי הבית (לבד מהדירות) כרכוש משותף. הוראות פרק 11 מחילות כאמור, בין היתר, גם את הוראות תיקון 18 לחוק על הבית דנן. בהתאם, הרי שזכות הנתבעים "לנצל" את זכויות בנייה יחסיות הקיימות בבית בהתאם לדין. גם הוראות הסכם החכירה של הנתבעים וגם הוראות הסכם הפיתוח של התובעת אינן מונעות שימוש בזכויות הבניה היחסיות האמורות המיוחסות לכל דירה ודירה.

30. שלישית, לא הוכחה קיומה של זכות כלשהי שנותרה עוד לתובעת 1 בבית בו ממוקמת דירת הנתבעים - מן הביקור במקום התרשמתי כי מדובר במבנה אשר נפרד לחלוטין ממבנים אחרים; האמור אינו עולה מהסכם הפיתוח, וודאי שלא לאור הסכמי החכירה בגין הדירות; הדברים אמורים גם לגבי התובעים האחרים - כל שבידם היא זכות חכירה בנוגע לדירותיהם וללא כל זכות כוללת במתחם.

בכל מקרה, אין בין התובעים דנן מי מבעלי הזכויות בדירות בבית בו ממוקמת דירת הנתבעים.

31. רביעית, בהתאם, אין כל יסוד קנייני לטענה בדבר זכויות הקיבוץ בנוגע לזכויות הבניה הקיימות - הסכמי החכירה הם המחייבים ואין כל ראייה בדבר "שימור" זכויות הבניה הניתנות למימוש בכל דירה פרטנית בבית הקונקרטי בידה של התובעת 1.

32. חמישית, גם תכנונית לא הוכח יסוד לטענת פגיעה בתובעת - מטעם התובעת לא הובאה כל עדות מקצועית אשר תתמוך בטענתה כי בידה אפשרות לכאורה לנייד את זכויות הבניה האמורות המיוחסות לכל דירה למקום אחר במתחם - לא הוגש חוות דעת אדריכלית, לא הוגשו מסמכים תכנוניים תומכים ולא הובא לעדות מי מנציגי הרשות המקומית לתמוך בטענה זו. מנגד, הוצא היתר בניה לתוספת האמורה ומהנדס העיר, אף שלא העיד כמומחה בתיק זה, אישר כי מדובר בזכויות בניה המוקנות לכל דירה. גם מחקירתו הנגדית לא עלתה כלל אפשרות ל"נייד" זכויות אלו לבניה אחרת של התובעת 1 במתחם.

33. למען הסר הטוב יובהר כי טענות התובעים בנוגע להיתר הבניה או בנוגע להליך הוצאתו יש להעלות בפני הערכאות והרשויות המוסמכות בהקשר זה. מכל מקום, בהליך שבפניי לא הוכח כי ההיתר שניתן בוטל והוא עודנו עומד בתוקפו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חצר

34. הבית דנן אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף ובהתאם חלות לגביו הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין. בהתאם, כל מה שאינו חלק מדירה הינו בגדר רכוש משותף (ר' סעיף 77 לחוק). לפיכך, חלקת האדמה בחזית הכניסה לדירת הנתבעים הינה, לכל היותר, בגדר רכוש משותף.

35. קביעה כאמור עולה גם מזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים אשר נגזרות, עד לרישום הבית המשותף, מהסכם החכירה אשר מקנה להם זכות בדירה מספר 1 בתשריט בה 3 חדרים בשטח של 79.5 מ"ר, הצמדות של ממ"ד בשטח 7.7 מ"ר, מחסן בשטח 5.4 מ"ר ומרפסת בשטח 37.0 מ"ר וחלק יחסי לא מוגדר ברכוש המשותף בבית (ר' נספח ד' לתצהיר אלברטון). הזכויות האמורות גם עולות מהסכם רכישת הזכויות על ידי הנתבעים (נספח ג' לתצהיר).

36. בביקור במקום התגלתה תמונה רחבה של השתלטות משמעותית של הנתבעים על חלקים שאינם "שייכים" לדירה, לא על פי ההגדרה החוקית כאמור ולא על פי הסכם החכירה - בחזית הבית קיימים "דק עץ עליו דשא סינטטי. המשטח מגודר במעקה מעץ, פרגולה, שמשיה, עץ, שולחנות מנגל" (עמוד 1 שורות 6-7).

37. בהעדר זכות קניינית בשטח המחלוקת ושעה שמדובר בשימוש ייחודי ברכוש באופן שמונע שימוש מאחרים, הרי שיש מקום להורות על סילוק ידם של הנתבעים מהשטח האמור. ויודגש, מן הביקור במקום והתמונות שצורפו עולה כי מדובר במעין חצר פרטית לשימוש הנתבעים עם מקומות לישיבה, מנגל, סככה וכיוצ"ב. במקום אף מותקנת תאורה, בשליטה מדירת הנתבעים, ריצוף, גינון וחנייה בשימוש הנתבעים (עמוד 1 שורות 9-10 ועמוד 2 שורה 11). די להפנות לתמונות נספחים ז ו- ח לתצהיר אלברטון כדי ללמד על קיומו של סיפוח השטח האמור לשימוש בלעדי של הנתבעים ומאז צילומים אלו התגלה בביקור במקום אף שימוש נרחב עוד יותר כפי שתואר לעיל שאינו מותר ספק בדבר ייחודיות השימוש.

38. ויוער, לאור מצבו הפיזי של השטח הרי שאף אם גם בעלי דירות אחרים עושים שימוש במקום (טענה שעלתה אך לא הוכחה, לרבות לא באמצעות העדת בעלי דירות שכנים) הרי שמדובר ב"אירוח" של האחרונים על גבי השטח האמור, ודאי במצבו כפי שהתגלה בביקור במקום.

39. זאת ועוד. הוכח בפניי כי הזכויות הקנייניות בשטח המחלוקת הנ"ל כלל אינן שייכות לבעלי הדירות בבית בו ממוקמת דירת הנתבעים.

40. ראשית, מדובר בחלקת אדמה שחורגת מתחום קונטור הבית והמעברים לו (ר' היתר בניה בנספח ב' לתצהיר אלברטון). למעשה, תחום הבית עובר במעבר הכניסה לבית והמדרגות המובילות לרחוב (ר' תמונות בנספח יד לתצהיר אלברטון ועמוד 2 שורות 1-2 לפרוטוקול ביקור במקום). ודאי אמורים הדברים כל עוד לא נרשם בית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. שנית, כל שיש בידי הנתבעים ובעלי הדירות האחרים במתחם מבחינה קניינית הינן זכויות חכירה על פי הסכמים שנחתמו מול מינהל מקרקעי ישראל. הסכמים אלו אינם מקנים בידי החוכרים זכויות כלשהן במתחם לבד מהזכויות בדירתם הקונקרטית כאמור לעיל. מאידך, הזכויות במגרש בכללותו נתונות בידיה של התובעת 1 על פי הסכם הפיתוח שחתמה עם ממ"י, מכוחו נבנו הבתים הקיימים כיום על המקרקעין וקיימת זכות להוסיף ולבנות עוד בתים נוספים, לרבות בשטח המדובר (ר' היתר בניה בנספח ב' לתצהיר אלברטון).
42. שלישית, לתוכנית המדידה (נספח 5 לתצהיר הנתבע) עליה מבססים הנתבעים את טענתם בדבר זכותם בשטח החצר אין כל ערך ראיתי – התוכנית לא הוגשה כדין באמצעות עורכה וממילא לא הוגשה כל חוות דעת מומחה; הוגש רק חלק מהתוכנית ולא ידוע כלל עבור מה ולאילו מטרה הוכנה; אין מדובר בתוכנית חתומה או מאושרת ועל פני הדברים מדובר במדידה של המצב בפועל, קרי, תיעוד להשתלטות הנתבעים. ויוער, תוכנית זו דווקא מחזקת את טענות התובעים בנוגע למעמדה של החצר – ניכר כי מדובר בחלק שהוא נפרד מהבית המשותף בו ממוקמת דירת הנתבעים, מחוץ לקו שביל הגישה לבית והמדרגות ממפלס הרחוב.
43. לנתבעים טענה בדבר קיומה של הסכמה לשימוש המבוצע על ידם. אולם, גם טענה זו אין בידי לקבל.
44. כל שהוסכם באסיפה מיום 04.10.08 עניינו בריצוף חלק מהחצר, ובעיקר, הקמת גדר תמך למניעת סחף (ר' נספח 1 לתצהיר הנתבע). לא הוסכם דבר בנוגע לשימוש בחלק החצר האמור, דבר שגם לא נעשה באותו מועד (כפי שניתן לראות גם בתמונה מוצג א).
45. גם "מכתב האשרור" (נספח 4 לתצהיר הנתבע) כל שיש בו הוא אישור בנוגע להסכמה שניתנה בעבר לבניית קיר תמך, הוספת דק והחלקת בטון (חלף הריצוף שהוסכם), גינון וצמחיה. המסמך מאשר במפורש כי הוא "לא מהווה אישור לחזקה על השטח ושהוא נשאר בגדר שטח משותף של הבניין" (ההדגשה במקור). יוצא, אם כן, כי גם הסכמה של בעלי הדירות לשימוש הנתבעים, ודאי זה אשר התגלה בביקור במקום, לא ניתנה – ניתנה הסכמה מסויגת וברורה להתקנת גדר תמך וריצוף בלבד, בעוד לשימוש שנעשה לא ניתנה כל הסכמה.
46. ויוזכר, כפי שגם הוסבר לעיל, הנתבעים חדלו מלהביא לעדות מטעמם את מי מבעלי הדירות בבית אשר מסכים, לכאורה, לפעולותיהם בבית, לרבות, השימוש בחצר. העדר עדותם של הנ"ל פועלת לחובת הנתבעים על פי ההלכה שאזכרה לעיל.
47. בנסיבות האמורות אף אם קניינית שטח האדמה היה חלק מהבית בו נמצאת דירת הנתבעים ומהווה רכוש משותף של בית זה (והדברים אינם כך כמוסבר לעיל) הרי שממילא אין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724; ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. למען שלמות התמונה אדגיש כי בכל הקשור לריצוף השטח והקמת קיר התמך הרי שניתנה הסכמת התובעת באמצעות מר אלברטון באסיפה מיום 04.10.18. מר אלברטון גם מאשר הסכמתו זו במסגרת חקירתו (עמוד 9 שורות 44-41). מהסכמה זו אין התובעים יכולים לחזור בהם עתה, ודאי כאשר טענתם היא כי התובעת 1 הינה בעלת הזכויות המהותית (סעיף 5 לתצהיר אלברטון).

49. לפיכך, יש לקבל את התביעה בכל הקשור לחצר בהתייחס לסילוק המטלטלין, הגדרות וכל אלמנט אחר אשר יש בו סממן לשימוש ייחודי. אולם, בכל הקשור לקיר התמך והריצוף שהותקן לחיזוקו (כיום דק) הרי שאלו יש להותיר במקומם, ללא רשות שימוש ייחודית לנתבעים, וזאת כל עוד לא תאושר כדין ותבוצע בנייה אחרת בשטח האמור.

נזקים

50. בכתב התביעה עותרים התובעים לחיוב הנתבעים "לשלם לתובעת מלוא הנזקים שנגרמו בגין פעולותיהם של הנתבעים".

51. אין בידי להיעתר לסעד המבוקש בהקשר זה.

52. ראשית, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בנזיקין, למעט, טענה בדבר הסגת גבול. בהתאם, כל נזק שעניינו בעילה אחרת אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית. זאת ועוד. מדובר בבקשה כללית לסעד שאיננה כוללת כל פירוט מספיק, כבר במסגרת כתב התביעה, ובכלל האמור לא פירוט לרכיבי הנזק הנטענים והערכת שיעורם.

53. שנית, בהעדר פירוט כאמור ממילא גם לא הוכח על ידי התובעים קיומו של כל נזק שנגרם בשל פעולות הנתבעים, ובוודאי שלא הוכח שיעור הנזק – אין כל ראיה בהקשר האמור במסגרת ראיות התובעים – לא בחוות דעת מומחה ואף לא בתצהירי העדות הראשית מטעמם.

54. טענה יחידה בהקשר זה יש מקום לקבל בנוגע לעץ אשר נעקר על ידי הנתבעים – הנתבע מאשר בעדותו כי עקר עץ ללא הסכמה ומחמת "טעות" (עמוד 13 שורות 25-22). בהתאם נכון יהיה לחייבו לשתול מחד עץ פרי בוגר במקום ממנו נעקר (עמוד 2 לפרוטוקול ביקור במקום שורה 11).

שיהוי ותום לב

55. בהתאם להלכה שיהוי בהגשת תביעה נוצר – "מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע" (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/38/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזובן ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 755-756; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54(54) (רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (פורסם בנבו)).

56. לא מצאתי מקום בנסיבות דנן לקבל את טענת הנתבעים בנוגע להתנהלות התובעים בהליך דנן - ראשית, בכל הקשור לבניה בדירת הנתבעים הרי שמדובר בפעולות שנעשו בחודש 12/13, עוד לפני הליכים להוצאת היתר בניה במהלך שנת 2014 (עמוד 12 שורות 22-23). ההליך הוגש בחודש 02/14 ובהתאם לוחות הזמנים עצמם אינם מקימים כל טענת שיהוי. ממילא גם מיד עם ביצוע הבניה נשלחו מכתבים על ידי התובעת ודבר התנגדותה היה ידוע לנתבעים. שנית, בכל הקשור לשימוש בחצר הרי שאומנם ניתנה הסכמה בשנת 2008 להקמת גדר תמך וריצוף כאמור. אולם, במסגרת הליך זה הוכח כי מדובר בהשתלטות הולכת ומתרחבת ושימוש שבגיניו לא התקבלה הסכמה. בהקשר זה די להשוות את מוצג א' לתמונות ז' ו- ח' למצב החצר בעת הביקור במקום כדי ללמוד על מגמה ברורה של השתלטות. לכך מתווספת גם ההסכמה המותנית המאושרת של בעלי הדירות במבנה בו נמצאת דירת הנתבעים מחודש 02/14, כולל ההתכתבויות, גם בנושא זה, כבר משנת 2012. לא ניתן בנסיבות אלו ללמוד על ויתור כלשהו מצד מי מהתובעים על זכויותיהם או טענותיהם. שלישית, ממילא לא הוכח כל שינוי מצב לרעה - הנתבעים "נהנו" משימוש ברכוש לא להלם או למצער ברכוש משותף ללא הסכמה כדין. הפסקת שימוש זה, כשלעצמו, אינו יכול להוות בגדר שינוי מצב לרעה. גם בכל הקשור לבניה בדירה הרי שמי שעושה דין לעצמו ובונה עוד בטרם נקט בהליכי תכנון ומבלי שקיבל הסכמות מפורשות אין לו לבוא בטענות אלא לעצמו.

57. גם את טענות הנתבעים בדבר חוסר תום לב בהגשת התובענה אין בידי לקבל.

58. אומנם, לא הוכח כי בוצעה חפירה בדירת הנתבעים. אומנם, הוכח כי ניתנה הסכמה לבינוי מסוים בחצר. אומנם, הוכח כי הרחבת הדירה בשטח הנדון בהיתר הבניה נעשתה כדין. אולם, סופו של יום הנתבעים הם אלו אשר עשו דין לעצמם - הרחיבו דירתם מעבר להיתר הבניה ללא קבלת הסכמה ושלא כדין, ביצעו את הבניה עוד בטרם קיבלו היתר כדין ונהגו מנהג בעלים בחצר שאין להם כל בעלות בה ולמצער מהווה, לכל היותר, רכוש משותף.

זכותם של התובעים להגן על קניינם, לרבות, באמצעות נקיטת ההליכים המשפטיים - אין בהתנהלות זו משום חוסר תום לב.

סיכום

59. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה כלהלן:

59.1. התביעה למתן צו מניעה אשר יאסור על ביצוע פעולות חפירה ובניה מתחת לשטח דירת הנתבעים ובכלל האמור הכנת שטח החפירה לשימוש ושימוש בו בפועל נדחית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/38/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אולם, מובהר בזה כי לשם ביצוע פעולות כאמור על הנתבעים לקבל תחילה הסכמה כדין של בעלי הדירות בבית, הסכמת התובעת בכל הקשור לזכויות בניה השייכות לה על פי הסכם הפיתוח ובכפוף לקבלת היתר בניה כדין.

59.2. בהתאם לאור לעיל צו המניעה מיום 18.02.14 מבוטל.

59.3. שעה שלא תוכננו עבודות חפירה וממילא לא בוצעו הרי שלא נגרם כל נזק לנתבעים עקב מתן הצו (בין היתר לאור הצהרתם בדיון מיום 18.02.14) אני מורה על השבת העירבון שהופקד בתיק ב"ב 01/39/14 לידי התובעים.

על ב"כ התובעים להגיש טפסים מתאימים בלשכת המפקח לשם קבלת ההחזר.

59.4. התביעה לסילוק יד של הנתבעים מהחצר מתקבלת כלהלן – אני מחייב את הנתבעים לסלק את ידם משטח החצר בחזית הדירה לכיוון מתחם החניה ובכלל האמור לסלק כל מיטלטלין שלהם במקום זה, לרבות, שולחנות, כסאות, מנגל, שמשיות, כלי רכב וכיוצ"ב.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לפרק כל קירוי וגדרות שהותקנו, למעט גדר התמך וריצוף הטרסה (כיום הדק) על התקנתה הסכימו, בין היתר, גם התובעת 1 כאמור.

האמור יבוצע על ידי הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.

59.5. אני אוסר על הנתבעים לשוב ולהניח מיטלטלין ו/או מחוברים באופן קבוע בשטח החצר האמורה או לעשות בה כל שינוי פיזי ללא קבלת הסכמת התובעת 1.

59.6. אני אוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש ייחודי בחצר ובכלל האמור לשם חניית כלי רכב באופן ייחודי.

59.7. התביעה להחזרת מצב דירת הנתבעים לקדמותו מתקבלת בחלקה כלהלן:

אני מחייב את הנתבעים להרוס את תוספת הבניה בדירתם באופן כזה שהבניה בבית תהיה תואמת את היתר הבניה בלבד – תוספת חדר בגודל של 10 מ"ר בשטח המרפסת.

יודגש, על הנתבעים לפתוח את הקירוי של המרפסת בדירתם ואת החלונות במרפסת שסגרו באופן כזה שהמצב הפיזי של המרפסת יחזור לקדמותו על פי היתר הבניה הקיים (כפוף לחדר שהוסף על פי היתר הבניה).

האמור יבוצע על ידי הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.

59.8. התביעה לתשלום נזקים נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/38/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59.9. אני מחייב את הנתבעים לשתול עץ פרי בוגר זהה לזה אשר נעקר (או עץ אחר בתיאום עם התובעים) במקום בו היה נטוע העץ שנעקר על ידם.

האמור יבוצע על ידי הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.

59.10. לאור תוצאות ההליך – קבלת התביעה בחלקה כאמור ומאידך דחייה, למעשה, של התביעה נושא הליך הסעד הזמני אשר פתח את הדיון בהליך, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות ובהתאם כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום א' כסלו תשע"ז, 01 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים